

1500104-88.2022.8.26.0666

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente e estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade e permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão "reiteradamente ou não", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500104-88.2022.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-88.2022.8.26.0666

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029103/2022 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 22762675 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 269/22/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2029103 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON LUIZ SOUSA ALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ROBSON LUIZ SOUSA ALVES, vulgo BÓ, e TIAGO MAZZER já qualificados nos autos, como incursos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso III, c.c. 35, caput, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei da Lei nº 11.343/06, Lei de Drogas, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, afirmando que em 01 de fevereiro de 2022, às 13h35min, na Rua José Ruivo Evangelista, n. 442, Bairro Itamaraty, CEP 13160-000, nesta cidade e Comarca de Artur Nogueira/SP, guardavam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, 31 (trinta e um) eppendorfs de cocaína e 03 (três) porções de maconha pesando, ao todo, 12,8g (doze gramas e oito decigramas). Consta, ainda, dos inclusos Autos de Prisão em Flagrante, que, em data incerta, mas anterior a 01 de fevereiro de 2022, os denunciados se associaram para praticar, nas imediações de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, reiteradamente, o tráfico de entorpecentes. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, ROBSON LUIZ SOUSA

ALVES, vulgo BÓ, e TIAGO MAZZER guardavam, na residência habitada por eles localizada ao lado do Bar do Gê, 31 (trinta e um) eppendorfs de cocaína e 03 (três) porções de maconha, destinados ao comércio espúrio de entorpecentes, os quais pesavam, respectivamente, 9,3g (nove gramas e três decigramas) e 3,5g (três gramas e cinco decigramas). ROBSON, vulgo BÓ, tentou se desfazer dos 31 (trinta e um) eppendorfs de cocaína, os jogando no vaso sanitário, porém a ação foi flagrada por Investigadores de Polícia e pela Guarda Municipal que cumpriam, no imóvel dos acusados, Mandado de Busca e Apreensão emitido nos autos n. 1500087-

52.2022.8.26.0666. Na área externa da casa, estava RAFAEL JULIÃO, que narrou à força policial ser usuário assíduo de maconha e estar ali para adquirir porções deste entorpecente por R\$ 10,00 (dez reais), sendo que já havia feito isto outras vezes, sendo que os denunciados sempre estavam no imóvel. Os acusados guardavam, por igual, na casa R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) em notas diversas, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações.

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O topo do art. 35 desta lei dispõe:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei".

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Já o tipo objetivo do topo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente e estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade e permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão "reiteradamente ou não", as decisões dos tribunais tem se consolidado neste sentido. O objeto material e jurídico é a paz pública.

No caso em exame, há prova da existência dos crimes e de sua autoria.

A existência dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelos laudos periciais (fls. 124/126) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

O investigador de polícia, Leonardo Pousada do Amaral, em fase policial disse que juntamente com o também investigador Gabriel de Queiroz e com o apoio dos Guardas Municipais, GCM Liberato e GCM Fantini entre outros, os quais deram cumprimento ao Mandado de Busca, na Rua José Ruivo Evangelista, n. 442 - Bairro Itamaraty- Artur Nogueira, expedido pelo juízo local, Foro da Comarca de Artur Nogueira, consoante o Processo n. 1500087-52.2022.8.26.0666, em investigação decorrente de Tráfico de Drogas. Assim, compareceram na residência alvo das investigações, uma vez que havia informações de que o local estava sendo utilizado para a guarda, armazenamento e distribuição de drogas, local esse que fica ao lado do "Bar do Gê", e já conhecido por outras apreensões de drogas. Estando naquela residência, já na área externa visualizaram, um rapaz que estava próximo a uma rede, identificado depois como sendo RAFAEL JULIÃO. Quando entraram na residência avistaram, de imediato, na cozinha um segundo indivíduo, o qual foi identificado posteriormente como sendo Tiago Mazzer. Ato contínuo, visualizaram um terceiro indivíduo que correu para os fundos do imóvel em direção a um banheiro, e o Investigador Gabriel de Queiroz, observou que um dos agentes da guarda municipal acompanhou esse indivíduo que correu para o banheiro, e o seguiu na porta do aludido banheiro, uma vez que tal

indivíduo, teria dispensado algo dentro do vaso sanitário. O o Investigador Gabriel, chegou próximo a porta do banheiro e ajudou a imobilizar aquele indivíduo, que teria jogado algo dentro do vaso sanitário, e observaram tratar-se dois sacos plásticos com vários pinos, eppendorfs, totalizando 31 pinos. Ao recuperarem os objetos que estavam dentro do vaso sanitário, constataram que eram pinos, contendo a substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína. O indivíduo que tentou dispensar as drogas no vaso sanitário foi identificado como sendo Robson Luiz Souza Alves. Diante disso, foi realizado vistoria no imóvel, sendo localizadas mais três porções de maconha, R\$ 199,00 em dinheiro, em notas diversas, aparelhos celulares e um caderno com anotações suspeitas. Indagada a pessoa de Rafael Julião, ele disse que era usuário de maconha e afirmou ter ido naquele local para comprar uma porção de maconha por R\$ 10,00. Ao ser indagado a pessoa de Tiago, este disse que conhece a pessoa de Robson, vulgo "Bó", e disse ter ido naquele local para comer um pão e falar com o Robson. Indagado a pessoa de Robson, a princípio teria dito aos policiais que era usuário de droga, de cocaína e questionado se sua esposa sabia que ele estava traficando, ele teria dito aos policiais que a esposa não tinha conhecimento que ele praticava o Tráfico de Drogas. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, Gabriel de Queiroz, prestou suas declarações no mesmo sentido do seu parceiro.

A testemunha de acusação, José Liberato de Souza, guarda municipal, disse que é Guarda Municipal e na data dos fatos, juntamente com o Investigador de Polícia, desta delegacia Gabriel de Queiroz, Leonardo Pousada, e dos Guardas Municipais, GCM Fantini entre outros, deram cumprimento ao Mandado de Busca, na Rua José Ruivo Evangelista, n. 442 - Bairro Itamaraty- Artur Nogueira, expedido pelo juízo local, Foro da Comarca de Artur Nogueira, consoante o Processo n. 1500087-

52.2022.8.26.0666, em investigação decorrente de Tráfico de Drogas. De posse da aludida da ordem autorizadora, compareceu na residência alvo das investigações, uma vez que havia informações de que o local estava sendo utilizado para a guarda, armazenamento e distribuição de drogas, local esse que fica ao lado do "Bar do Gê", e já conhecido por outras apreensões de drogas. Estando naquela residência, já na área externa visualizaram, um rapaz que estava próximo a uma rede, identificado depois como sendo RAFAEL JULIAO. Que de imediato entraram na residência e na cozinha já avistaram um segundo indivíduo, o qual foi identificado posteriormente como sendo Tiago Mazzer, e ato contínuo, visualizaram um terceiro indivíduo que correu para os fundos do imóvel em direção a um banheiro, e o o depoente teria acompanhado esse indivíduo que correu para o banheiro, e o seguro na porta do aludido banheiro, uma vez que tal indivíduo, teria dispensado algo dentro do vaso sanitário e foi auxiliado pelo Investigador Gabriel de Queiroz, os quais imobilizaram aquele indivíduo, que teria jogado algo dentro do vaso sanitário, e observaram tratar-se dois sacos plásticos com vários pinos, eppendorfs. Que o referido indivíduo foi imobilizado e algemado, e ao recuperarem os objetos que estavam dentro do vaso sanitário, constataram que eram pinos, contendo a substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína, totalizando 31 pinos. Que o indivíduo que tentou dispensar as drogas no vaso sanitário foi identificado como sendo Robson Luiz Souza Alves. Que diante disso foi realizado vistoria no imóvel, sendo localizado mais três porções de maconha, R\$ 199,00 em dinheiro, em notas diversas, aparelhos celulares e um caderno com anotações suspeitas. Que indagado a pessoa de Rafael Julião, esse disse que era usuário de maconha e afirmou ter ido naquele local para comprar uma porção de maconha por R\$ 10,00. Ao ser indagado a pessoa de Tiago, este disse que conhece a pessoa de Robson, vulgo "Bó", e disse ter ido naquele local para comer um pão e falar com o Robson. Indagado a pessoa de Robson, a princípio teria dito aos policiais que era usuário de droga, de cocaína, e questionado se sua esposa sabia que ele estava traficando, ele teria dito aos policiais que a esposa não tinha conhecimento que ele praticava o Tráfico de Drogas. Diante do cenário e dos indícios e da localização da droga, conduziram as pessoas de Robson, Tiago e Rafael, até esta Delegacia, bem como apresentaram as drogas o dinheiro e os aparelhos celulares dos investigados, para as providências de polícia judiciária cabíveis ao evento. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, Rafael Julião, em fase policial, disse que reside nesta cidade de Artur Nogueira com seus pais, no bairro Itamaraty. Disse que trabalha de controlador de acesso em um Condomínio na cidade de Cidade de Engenheiro Coelho, e disse que hoje vai trabalhar após às 18 horas em sua escala. Disse que é usuário assíduo de maconha. Disse que hoje por volta das 13 horas, saiu de sua casa, e foi em direção a Rua José Ruivo Evangelista, n. 442, residência da pessoa conhecida como "Bó", de nome Robson, Que foi até aquele local para adquirir maconha para seu uso. Disse que conhece a pessoa de Robson pois ele namora a mãe de um amigo. Perguntado disse que já foi até aquele local umas duas vezes, para comprar droga, maconha para seu uso. Disse que por algumas vezes, quando vai naquele local para comprar drogas, sempre visualizava e falava com a pessoa de Robson, bem como sempre via a pessoa de Tiago Mazzer que ficava naquele local, com Robson, vulgo "Bó". Na data dos fatos, ao chegar naquele local, com o intuito de comprar maconha para seu uso, entrou na residência, e ficou do lado externo, em uma área coberta, aguardando, pois Robson teria pedido para ele aguardar um pouco e entrado naquela residência, sendo que a pessoa de Tiago estava no interior da residência juntamente com o Robson. Disse que enquanto estava aguardando na área externa, para adquirir uma porção de maconha por R\$ 10,00, os policiais chegaram naquele local, e foi abordado e visualizou que os policiais adentraram na residência e abordaram a pessoa de Robson vulgo Bó, bem como Tiago Mazzer, e após vistoriaram o imóvel, e tomou conhecimento de que eles localizaram certa quantidade de droga, mas não acompanhou a diligência pois ficou detido do lado de fora, aguardando as diligências e após a finalização, foi conduzido até esta Delegacia para ser ouvido sobre os fatos. Disse que nunca foi preso, e não responde a nenhum processo criminal, e que é apenas usuário de drogas, maconha, e nega a prática do tráfico. ROBSON LUIZ SOUSA ALVES, em seu interrogatório na fase policial, disse que reside nesta cidade de Artur Nogueira juntamente com seu filho e sua mãe esposa. Disse que já foi preso por tráfico de droga e alegou que nesta data teria acabado de chegar do serviço, onde monta estufa, na cidade de Holambra. Contou que, ao chegar do seu serviço a pessoa de Rafael Julião, estava na residência pois ele conhece o enteado do interrogado e teria vendido uma correntinha de prata, para o enteado, e RAFAEL teria ido até a sua casa para receber o dinheiro do objeto que vendera. Sobre Tiago Mazzer, disse que o conhece já há algum tempo e ele teria ido em sua casa, para usarem maconha juntos, pois são usuários de maconha e cocaína. Disse que quando os policiais chegaram em sua residência ele tinha acabado de comprar droga para usar juntamente com Tiago Mazzer, e que ficou assustado pois já ficou preso por tráfico de drogas. Disse que tentou dispensar a droga, os pinos no vaso sanitário no banheiro da casa onde reside, e foi imobilizado pelos policiais, e algemado sendo que os policiais recolheram o objeto que ele teria jogado no vaso sanitário. Alega que foi agredido quando tentaram algemá-lo Perguntado sobre praticar o tráfico de droga, o interrogado disse que apenas teria comprado os dois quites de pinos de cocaína, pelo valor de R\$ 600,00 e que iria usar todos os pinos, pois asseverou ser usuário assíduo e usa todos os dias. Negou a prática do tráfico de droga no bairro Itamarati, e perguntado se conhece quem seja o responsável pela distribuição de drogas naquele bairro, disse que desconhece. Após a diligência em sua residência, em que os policiais localizaram a droga que ele teria jogado vaso do banheiro, bem como localizaram 3 (três) porções de maconha, e disse que a maconha localizada era também para o seu uso. Em juízo, manteve a versão dos fatos. TIAGO MAZZER, em seu interrogatório na fase policial, disse que reside nessa cidade de Artur Nogueira juntamente com seu filho e sua mãe e seu irmão. Disse que já foi preso por tráfico de drogas, e alegou que nesta data teria saído de sua casa para ir comer pão na casa da pessoa de Robson, pois conhece a esposa dele há algum tempo. Disse que é usuário de maconha. Contou que quando os policiais adentraram naquela residência ele estava apenas na cozinha, comendo um pão. Disse que não visualizou os policiais localizarem a droga que estava com Robson. Que ao ser abordado pelos policiais, afirmou que estava comendo pão e não viu os policiais localizarem a droga na residência. Perguntado sobre se sabe da droga que foi localizada na residência, o interrogado desconhece, e não sabe a quem pertence, dizendo ser apenas usuário de maconha, negando estar praticando o tráfico de

drogas. Perguntado se tem conhecimento de quem seria a pessoa que teria fornecido a droga para pessoa de Robson, o interrogado disse que desconhece e não sabe dizer. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

Embora tenham negados os fatos, as versões dadas pelos acusados não encontram respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isoladas. Até porque foram incapazes de infirmar o restante do contexto probatório, que lhes é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência das condutas guardar entorpecentes e a autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar os réus.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes os réus e seus defensores, tiveram estas plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado darão policiais crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.x STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009.

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 20.08.2013.

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreiamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante". TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 08.08.2018.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da

Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, além do passado dos réus ligado à criminalidade indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial. Ademais, a condenação pelo topo do art. 35, por si, descaracteriza a situação exigida pelo topo do art. 28.

Assim, ficou provado o tipo objetivo e subjetivo do delito de tráfico.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Quanto ao delito de associação, entendo que não restou devidamente comprovada a associação para o tráfico ilícito de entorpecente, ou seja, a reunião estável e permanente de duas pessoas para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, os delitos previstos nos artigos 33, "caput", e parágrafo 1º, e 34, ambos da Lei n. 11.343/06. Isso porque, as provas dos autos não indicam a função de cada um na sociedade e nem mesmo a ligação entre eles durante a atividade criminosa. Passo a dosar a pena

Passo a dosar a pena.

Ante a semelhança de condições dos réus, realizo a dosimetria una.

Primeira etapa. Analisando as circunstâncias judiciais, anoto que possui maus antecedentes, pelo que elevo em 1/6 a pena base, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 588 dias-multa.

Segunda etapa. Ausentes atenuantes. A confissão relativa ao uso da droga não enseja a incidência da atenuante quando da condenação por tráfico:

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, observa-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, e não merece reparo. O benefício foi negado ao paciente por ter ele assumido, tão somente, a posse da droga para consumo próprio, e não propriamente o tráfico de entorpecente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a confissão espontânea do agente, sentenciado por tráfico de entorpecentes, de ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. A propósito: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

PACIENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO, ALEGANDO SER MERO USUÁRIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu admita a prática do crime que lhe é imputado, contribuindo, assim, com o deslinde da persecução criminal. Na espécie, o Tribunal de origem destacou que o paciente negou a prática delitativa em juízo, alegando que teria comprado o entorpecente apenas para consumo e não para a mercancia, razão pela qual não deve incidir, na espécie, a referida atenuante. 2. Ante o não acolhimento do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resta prejudicado o pleito de compensação da agravante da reincidência com a referida atenuante. 3. Habeas corpus não conhecido." HC 373.054/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 4/5/2017.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. TRANSPORTADOR DE DROGAS. MULA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 65, III, 'D', DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE QUE NÃO SE APLICA PARA CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS QUE RECONHECE APENAS O USO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de prova, que a ré, presa enquanto praticava o transporte internacional de drogas, integrava organização criminosa, sendo inviável afastar tal constatação, em razão do vedado revolvimento fático-probatório, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A confissão espontânea pela prática de uso de drogas não enseja a

aplicação da referida atenuante se o réu foi condenado por tráfico de drogas, conforme jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido." AgRg no AgRg no AREsp 1.053.604/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017. STJ, HC 431541/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Presente a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé fls. 90/95), razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando em 6 anos e 9 meses e 680 dias-multa. Terceira etapa: Ausente causas de diminuição. Incabível o redutor. As drogas foram apreendidas após cumprimento de mandado de busca motivados por denúncias aos policiais da cidade. Todo esse caminho, que foi da percepção dos populares, passando pela comunicação do delito aos servidores encarregados da segurança pública, diligências de investigação, solicitação da busca, terminando em cumprimento de mandado, revela a permanência e reiteração do agente no comércio ilícito denotando sua dedicação às atividades criminosas, o que é reforçado pela ausência de ocupação lícita regular.

Afasto a causa de aumento do artigo 40, III, tendo em vista que o Bar do Gê se trata tão somente de um estabelecimento comercial do estilo "boteco", não se prestando a finalidade de "diversão" prevista pelo legislador.

Fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A reincidência também impede a aplicação do redutor, a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional. Neste sentido:

"A agravante obsta o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, juntamente com a pena corporal, obrigava a fixação do regime inicial fechado e impedia a substituição por restritivas de direitos." TJSP, Apelação n. 0000411-36.2016.8.26.0599, Rel. Des. Vico Manãs, j. 23.05.2018.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER ROBSON LUIZ SOUSA ALVES e TIAGO MAZZER da imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal e CONDENAR ROBSON LUIZ SOUSA ALVES à pena de reclusão, pelo prazo de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, em regime inicial fechado, bem como a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas no topo do artigo 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e CONDENAR TIAGO MAZZER à pena de reclusão, pelo prazo de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, bem como a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas no topo do artigo 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta dos acusados, as razões das prisões cautelares estão mantidas.

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". (...) 5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma,

RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

"3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. 4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas). 5. Ordem denegada." STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança nos regimes prisionais.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que foiram nomeados advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Artur Nogueira, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA